

1521388-45.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cecilia Pinheiro da Fonseca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... dúvidas de que o réu praticava o crime de tráfico de drogas.

A propósito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado, ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL - BARRA FUNDA

3ª Vara Criminal

1521388-45.2021.8.26.0228 - pág.

CONCLUSÃO

Em 27/01/2022, faço estes autos conclusos a(o) Exmo(a). Dr(a). Cecilia Pinheiro da Fonseca, Juiz(a) de Direito. Eu, _____, Escrevente, digitei e subscrevi.

SENTENÇA

Vistos.

RAFAEL AUGUSTO MARQUES GRATIERI, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", c.c o artigo 33, §1º, incisos I e II, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 04 de setembro de 2021, às 10h36minhoras, na Rua Vera Cruz, 136, Penha, São Paulo, Capital, produziu e tinha em depósito, cultivava, semeava e fazia a colheita de plantas que se constituem em matéria-prima e insumo para a preparação de drogas, a saber: 711,2g de "Cannabis sativa L." em pés de maconha, vulgarmente conhecida como "maconha" e guardava uma porção de maconha, pesando cerca de 2,4g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de diversos produtos de jardinagem, conforme boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, e laudo de constatação.

Conforme a inicial, policiais civis receberam denúncia anônima noticiando o plantio de maconha que estaria sendo cultivada nos fundos da residência do acusado.

Após diligências iniciais, foi solicitado apoio à Polícia Militar, razão pela qual os milicianos dirigiram-se ao local e constataram a veracidade das informações. Segundo consta, no momento da abordagem os policiais foram recebidos por Dalva de Paula Marques e Gabriel Augusto Marques Gratieri, que indicaram a casa do acusado. Neste momento, o réu saiu de sua casa e veio ao encontro dos policiais; indagado informalmente, o réu confirmou que mantinha uma estufa na garagem, onde plantava maconha. Ato contínuo, acompanhou os policiais até sua garagem, sendo encontrada a estufa em funcionamento, com sistema de iluminação e ventilação, contendo quatro vasos com plantas aparentando ser "Cannabis Sativa L". Foram localizadas também

folhas secas e fragmentos vegetais de maconha, além de diversos materiais de jardinagem.

Questionado acerca da existência de outras drogas em sua residência, o acusado informou que tinha uma porção de maconha para consumo pessoal. Em seguida, entregou aos policiais um saco plástico contendo maconha.

Assim, segundo a denúncia, as drogas foram encontradas em diferentes estágios: em sementes, plantadas, bem como a traficância restou caracterizada, tendo em vista a localização da estrutura organizada para o cultivo de maconha e dos demais objetos, a confissão informal do acusado e as circunstâncias da prisão.

O réu foi devidamente notificado e apresentou defesa preliminar. Na sequência, a denúncia definitivamente recebida.

Na data de hoje, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela Acusação e um informante arrolado pela Defesa, sendo, ao final, o réu interrogado.

Assim, finda a instrução, em debates, o Ministério Público pleiteou a condenação, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição e deduziu pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento.

Inicialmente, rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo réu em sede de resposta à acusação, uma vez que a denúncia preencheu todos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo com detalhes os fatos imputados ao réu e lhe permitindo, portanto, o pleno exercício do direito de defesa.

No mais, não há que se falar em nulidade do flagrante, porquanto observados todos ditames legais pertinentes, enfatizando a situação de flagrância, acrescentando que não é, no mais, o caso de se fazer acareação entre os depoimentos prestados pelos policiais militares e o teor do interrogatório do réu.

Dessa forma, vencidas as questões preliminares, no mérito, não obstante o esforço combativo do Nobre Defensor, o pedido formulado na denúncia é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo próprio auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, fotografias, pelo laudo de constatação e laudo de exame químico toxicológico. A droga foi submetida à perícia, que revelou tratar-se de maconha; ademais, a materialidade delitiva ainda encontra base na prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

Na fase extrajudicial, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu alegou ser usuário de maconha e confirmou que a estufa encontrada na garagem de sua residência lhe pertence, porém, as plantas produzidas destinam-se ao seu consumo pessoal; que tem medo de se dirigir aos pontos de venda para adquirir droga; que, há cerca de três meses, ganhou uma porção de maconha, prensada e, então, retirou as sementes da referida porção e decidiu plantar para o seu próprio consumo, sendo a primeira vez que improvisou a estufa e decidiu cultivar as plantas para o seu consumo pessoal; alega que jamais vendeu e não pretendia vender droga a ninguém e, em relação aos demais materiais encontrados na garagem, informa que possui uma loja na "internet", denominada "Plantaiz" (plantaiz.com.br), e possui na garagem estufas, vasos, substratos, fertilizantes e materiais em geral para o cultivo "indoor", com nota fiscal de todos os materiais; o réu também confirmou que matinha em sua casa um pequeno saquinho contendo uma porção de maconha e que ganhou referida porção de um amigo, seno que prontamente apresentou a substância aos policiais militares; afirmou, ainda, ser bancário e trabalhar no "C6 Bank", com pós-graduação em gestão em tecnologia da informação; que nunca foi preso, nem processado criminalmente e, a pedido do advogado presente, consigna que não integra nenhuma facção criminosa.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado novamente negou a prática do delito narrado na denúncia, repetindo a versão dada em solo policial.

Entretanto, a negativa do acusado não encontra respaldo suficiente nos autos, sendo que, diversamente, os elementos de prova trazidos permitem a condenação, nos termos da denúncia, sem espaço para absolvição nem desclassificação.

Os policiais militares, Elaine e Edson, ouvidos em fase extrajudicial e também hoje em Juízo, relataram que, na data dos fatos, foram acionados pelos superiores hierárquicos para averiguarem os fatos constantes da denúncia anônima n. W2109020305, versando sobre tráfico de drogas, em residência; segundo constava, o acusado, mantinha uma estufa na garagem da casa, com plantas, a saber, pés de maconha. Chegando ao local, os policiais chamaram os moradores, e foram recebidos inicialmente pela Sra. Dalva de Paula Marques, idosa, e pelo neto dela, Gabriel Augusto Marques Gratieri, eles que informaram que o réu era morador da casa dos fundos, onde residia com a esposa. Ademais, a Sra. Dalva e o neto Gabriel disseram que desconheciam os fatos narrados na denúncia anônima e de pronto franquearam a entrada dos policiais na residência; ainda, durante o contato inicial com a Sra. Dalva e o neto Gabriel, o acusado saiu de sua residência e veio ao encontro dos policiais; indagado, o acusado confirmou que mantinha uma estufa na garagem, onde plantava maconha e que a droga se destinava ao seu consumo pessoal. Ato contínuo, o réu acompanhou os depoentes até a garagem e, ali chegando, foi encontrada uma estufa em funcionamento, com sistemas de iluminação e ventilação, contendo cerca de quatro vasos com plantas que aparentavam ser "Cannabis sativa"; ademais, na garagem havia grande quantidade de materiais relacionados a jardinagem; em relação aos materiais encontrados, o acusado informou que possuía uma loja na "internet", para venda de produtos de jardinagem. Indagado se havia algo mais ilícito na residência, o réu disse que havia droga no interior da casa dele, para consumo pessoal; assim, os policiais acompanharam o réu até sua residência, situada na parte dos fundos do imóvel; os policiais o aguardaram na porta, não chegando a entrar na residência; então, o acusado entrou na casa e pegou um saquinho plástico, que se encontrava sobre a mesa da cozinha, contendo pequena porção de substância esverdeada, que aparentava ser maconha. Em seguida, foi dada voz de prisão ao acusado, sendo ele encaminhado à delegacia. Não foi necessário o emprego de algemas.

Essa foi a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, que permite a condenação, nos termos da denúncia.

Veja-se que não há dúvidas de que o réu praticava o crime de tráfico de drogas.

A propósito:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado, ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (TJRN, Ap. 99.000136-9, Câm. Crim., j. 15-10-1999, rel. Dês. Armando da Costa Ferreira, RT 776/663).

Importante salientar, desde logo, que não existe nenhuma circunstância que justifique o interesse dos policiais em prejudicar o réu.

Assim, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se

evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF HC nº 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

As testemunhas arroladas pela Acusação apenas confirmaram os fatos descritos na denúncia.

Na ponderação de valores dos depoimentos, não tenho dúvidas de que devem prevalecer as palavras dos policiais.

Não se olvide que a condição de usuário também não é suficiente para a absolvição do réu, pois isso não é incompatível com a figura do tráfico, sendo certo que várias pessoas sustentam o seu hábito com a venda de drogas.

Assim, conquanto tenha declarado que é usuário de drogas, está demonstrada nos autos a finalidade mercantil com que o réu semeava, cultivava e fazia a colheita das plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas, além de tê-las em depósito e guardá-las.

Não há, pois, qualquer dúvida de que a intenção do acusado era a de entregá-las ao consumo de terceiros. Portanto, torna-se absolutamente incabível considerar a hipótese de desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28, § 1º, da Lei nº 11.343/06.

Assim, o crime de tráfico de entorpecentes de consumou, pois o réu praticou os elementos "ter em depósito, guardar, semear, cultivar e fazer a colheita" constantes do tipo penal alternativo, sendo irrelevante, para tanto, a efetiva entrega ao consumo de terceiros, por se tratar o tráfico de crime formal e de perigo abstrato (não exige resultado naturalístico para a consumação, consistente na efetiva lesão à saúde de alguém).

Comprovadas, portanto a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado pelo Ministério Público na denúncia, de rigor a procedência da pretensão punitiva estatal em face do réu.

Por fim, destaco que o depoimento prestado pelo informante arrolado pela Defesa, Gabriel, irmão do acusado, não teve o condão de macular a farta prova produzida no sentido da condenação.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem-se que a pena-base do réu deve ser fixada no patamar mínimo cominado à espécie, isto é, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Em seguida, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, nada a modificar.

Por fim, na terceira fase de aplicação da pena, ausentes causas de aumento, aplico a diminuição de pena prevista pelo §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada, ainda que de ofício. A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário: "Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em

atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda" (GRECCO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2ª Ed., 2008, p. 106-107).

Com fulcro em tal lição doutrinária e na análise das provas produzidas em juízo, de rigor se considerar a causa de diminuição da pena, eis que não restaram comprovados quaisquer dos óbices aduzidos no texto de lei sob comento: não primariedade, ausência de bons antecedentes, dedicação a atividades criminosas e participação em associações criminosas. Resta agora, porém, discorrer acerca do percentual de redução. Neste passo, tenho por mais acertada a lição doutrinária contida na obra acima referida que preconiza a aplicação da regra do art. 42 da Lei 11.343/06, o qual determina que na fixação das penas, serão considerados, com preponderância, os critérios do art. 59 do Código Penal, juntamente com a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido.

Neste sentido, aliás, encontramos o mais recente abalizado entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). PENA FIXADA EM 5 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º. DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 NA PROPORÇÃO DE 1/3. PENA CONCRETIZADA: 3 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. EXAME FAVORÁVEL DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGENTE PRIMÁRIO E POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER MINISTERIAL PELO DEFERIMENTO DO WRIT.1. Se o legislador da Lei 11.343/06 não forneceu especificamente os requisitos para fixação do quantum da diminuição prevista no seu artigo 33, § 4º, impõe-se como critério a observância da análise das circunstâncias judiciais, não só as constantes do artigo 59 do CPB, como as demais mencionadas na Lei Antidrogas, e amplamente utilizadas como referencial quando se trata de fixação das penas previstas.2. (...).3. (...).4. (...)." (HC 120.832/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julg. 04/06/2009, DJE 03/08/2009).

Diante de tais ponderações e das constatações das provas produzidas, sobretudo levando-se em consideração a quantidade e espécie da substância entorpecente encontrada (maconha), reduzo a pena em grau máximo, atendendo-se aos critérios de proporcionalidade que decorrem da própria norma que estipula um parâmetro dentro do qual a redução deve ser realizada. Como consequência, a pena passa para o patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso mínimo, atualizado.

Diante da quantidade da pena privativa de liberdade ora aplicada e considerada a primariedade do acusado, excepcionalmente, atenta às particularidades do caso, entendo cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes, do Código Penal.

Assim, tratando-se de pena superior a um ano, substitui-se a pena corporal por duas restritivas de direitos, conforme prevê o artigo 44, § 2º, do Código Penal. A primeira restritiva de direitos será a prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período de pena substituída. Os serviços serão prestados em entidade a ser indicada por ocasião da execução. A segunda restritiva de direitos será a prestação pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo que será destinado à entidade a ser indicada por ocasião da execução.

Em caso de descumprimento das restritivas de direitos e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, considerando as peculiaridades do caso.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado RAFAEL

AUGUSTO MARQUES GRATIERI, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", c.c o artigo 33, §1º, incisos I e II, da Lei nº 11.343/06, e, via de consequência, aplico-lhe as penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, na forma acima especificada.

Faculto o recurso em liberdade.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento.

Determino a incineração da droga apreendida, oficiando-se.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e, oportunamente, arquivem-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de janeiro de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Cecilia Pinheiro da Fonseca

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA